

1504356-90.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Carla de Oliveira Pinto Ferrari

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 20ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/04/2022

... CORPUS SUBSTITUTIVO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO COM BASE NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS. REEXAME PROBATÓRIO. REDUÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PATAMAR DIVERSO DE 2/3. AUSÊNCIA DE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

20ª Vara Criminal

Av Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1504356-90.2022.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1504356-90.2022.8.26.0228, c. 249/22

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
(COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2050209/2022 - 33º D.P. PIRITUBA, 23162418 - 33º D.P. PIRITUBA, 815/22/333 - 33º D.P. PIRITUBA, 2050209 - 33º D.P. PIRITUBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCELO ALBUQUERQUE DE ALMEIDA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carla de Oliveira Pinto Ferrari

Vistos.

MARCELO ALBURQUEQUE DE ALMEIDA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, c/c art. 61, inc. II, 'j', do Código Penal, porque no dia 21 de fevereiro de 2022, por volta das 09h30min, na Rua Saloa, 84, São Domingos, nesta cidade e comarca de São Paulo, nesta cidade e comarca de São Paulo/SP, trazia consigo, 33 (trinta e três) porções de droga

popularmente conhecida como maconha (103,7g - cento e três gramas e sete decigramas), 76 (setenta e seis) porções de cocaína (29,5g - vinte e nove gramas e cinco decigramas), e 379 (trezentos e setenta e nove) porções de cocaína sob a forma de crack (76,6g - setenta e seis gramas e seis decigramas), substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com a determinação legal.

Em 03 de março de 2022 houve a determinação para a notificação do réu e apresentação de defesa preliminar (fls. 99/105).

O réu foi notificado (fls. 150) e ofertou defesa preliminar às fls. 123/127, arrolando as mesmas testemunhas da acusação.

A denúncia foi recebida em 14 de março de 2022 (fls. 136) e o réu foi devidamente citado (fls. 163).

Durante a instrução processual foram ouvidas as testemunhas arroladas em comum pela acusação e defesa, sendo, em seguida, o réu interrogado. Não foram requeridas diligências pelas partes.

Em debates orais, a representante do Ministério Público reportou-se ao contido nos autos, pedindo a condenação do réu nos termos da denúncia. Com relação às penas, pediu a fixação acima do mínimo legal, não incidência da agravante da calamidade pública, incidência da agravante da reincidência, não aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33 § 4º da Lei nº 11.343/2006 e o regime inicial fechado para início de cumprimento. Postulou o encaminhamento de cópias para instauração de inquérito policial para apuração de crime de falso testemunho em relação à testemunha Carlos.

A Defensora constituída postulou a incidência do redutor em seu grau máximo, com fixação de regime aberto. Em caso de não aplicação do redutor, postulou a fixação da pena no mínimo legal.

É o relatório do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão estatal deve ser julgada procedente.

A testemunha Carlos narrou que na data dos fatos estavam em companhia do réu e de Ryan, sendo que todos faziam consumo de maconha, sendo que ainda estavam fumando quando foram abordados. Não tinham isqueiro consigo, sendo que pediram emprestado um isqueiro a um morador que passou pelo local. Após serem abordados, disse que os policiais desceram um beco e retornaram com uma sacola. Em seguida, foram levados para o Distrito Policial. Os cigarros que fumavam foram apreendidos pelos policiais.

Os policiais militares narraram que na data dos fatos efetuavam patrulhamento de rotina quando passaram por local conhecido como ponto de tráfico e avistaram algumas pessoas no final de uma viela, o que levantou suspeita. Desembarcaram da viatura e efetuaram incursão a pé. Visualizaram três indivíduos sentados, sendo que viram o momento em que o réu dispensou ao lado dele uma sacola verde. Procederam à abordagem dos três indivíduos. Em revista pessoal, encontraram apenas certa quantia de dinheiro em poder de Ryan. Dentro da sacola dispensada pelo réu encontraram porções fracionadas e maconha, cocaína e crack, bem como a quantia aproximada de R\$ 380 em notas trocadas. O réu confessou a prática delitiva. Ryan disse que trabalhava no tráfico no local, mas que naquele dia não estava traficando, afirmando que ali estava apenas para usar drogas. Carlos disse que estava ali apenas para fazer uso de drogas. Com eles não havia qualquer droga, tampouco apetrecho para uso de drogas. Não os conheciam anteriormente. O réu disse que residia nas proximidades. Nenhum deles parecia estar sob efeito de drogas. Ninguém interveio em favor deles durante a abordagem.

O réu em seu interrogatório confessou a prática delitiva. Disse que estava com uma dívida para consertar sua moto e que decidiu vender drogas para conseguir quitá-la. Havia dois dias que trabalhava vendendo drogas no local, ganhando R\$ 200 por dia. Não conhecia os policiais anteriormente e não houve qualquer agressão durante a abordagem.

Assim, é de se concluir pela existência da prática de tráfico pelo réu, o que se extrai da conjugação dos seguintes fatores: quantidade, variedade e forma de

condicionamento das drogas, que estavam fracionadas e prontas para a entrega a usuários; a incompatibilidade entre a quantidade de drogas e a condição financeira do réu; ausência de demonstração que a droga destinava-se para seu consumo próprio; a prisão ocorreu em um local conhecido como ponto de tráfico; as circunstâncias da prisão em flagrante, sendo que os policiais visualizaram o réu segurando a sacola que continha os entorpecentes; a localização de dinheiro em notas trocadas em poder do réu; além de o réu ter confessado a traficância, informalmente, no momento de sua prisão.

Em caso análogo já decidiu o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"TESTEMUNHA - Tóxico - Depoimentos prestados por policiais - Validade - Inexistência de razão concreta para suspeição - Relatos que merecem a normal credibilidade das testemunhas em geral - Interpretação do artigo 202 do Código de Processo Penal - Recurso não provido.

PROVA CRIMINAL - Tóxicos - Drogas apreendidas na residência da ré que não produziu qualquer prova de que não fossem de sua propriedade - Recurso não provido.

PROVA CRIMINAL - Tóxicos - Casa conhecida como local de venda de entorpecentes, quantidade e condicionamento da droga apreendida que nenhuma dúvida deixam a respeito da destinação comercial do produto - Recurso não provido." (Ap. Crim. nº 247.848-3 - São Paulo - 6ª Câ. Crim. de "Julho/98" - Rel. Debatin Cardoso - J. 13.08.98 - v.u).

Os policiais ouvidos procederam a relatos detalhados, uníssonos e harmônicos entre si, ratificando-se o que falaram na fase policial, nada havendo nos autos que possa extrair a validade de suas palavras. Trata-se de agentes públicos, dotados de fé pública, aos quais são conferidos poderes para fins de polícia preventiva e repressiva, não sendo razoável que, apenas em Juízo, suas declarações sejam recebidas sem o devido valor.

A palavra deles não merece descrédito, tendo em vista que o réu não noticiou que os conhecia anteriormente, inexistindo motivos para que eles pretendessem legitimar a prisão realizada. São agentes públicos dotados de presunção de boa-fé, até prova em contrário, cuja produção estaria a cargo da defesa, que não se desincumbiu de tal ônus nestes autos. Não seria coerente conferir-se ao policial a presunção de legitimidade para realizar as funções que lhe compete, como a de policiamento ostensivo e abordagem a suspeito, para depois, em Juízo, extrair-se de suas palavras a validade necessária. Esclarecedora a seguinte transcrição

"PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO COM BASE NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS. REEXAME PROBATÓRIO. REDUÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PATAMAR DIVERSO DE 2/3. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. ILEGALIDADE. CUMPRIMENTO DA PENA. REGIME INICIAL MAIS RIGOROSO. RÉU PRIMÁRIO. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. GRAVIDADE ABSTRATA. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. REDIMENSIONAMENTO. (...)

2. O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso" (STJ, HC 165561 / AM, rel. Min. NEFI CORDEIRO, j. 02/02/2016)

Observo que pequenas contradições, não essenciais aos fatos, apenas ratificam a veracidade de seus depoimentos, pois indicam de forma clara que não houve prévio ajuste sobre a versão que deveria ser ofertada, baseando-se seus relatos exclusivamente na memória que têm do dia dos fatos.

A materialidade delitiva está comprovada pelo exame químico-toxicológico de fls. 156/158, que atestou positivamente para cocaína e tetrahidrocannabinol (THC), além do auto de exibição e apreensão (fls. 10/11).

Irrelevante que o réu não tenha sido surpreendido comercializando os entorpecentes, pois se trata de tipo misto alternativo, bastando a prática de qualquer dos seus verbos nucleares para sua configuração, sendo que no presente caso trazia consigo, as drogas supramencionadas.

Quanto à agravante da calamidade pública descrita na denúncia, muito embora esta

magistrada viesse reconhecendo a sua incidência em todos os crimes praticados desde a edição do Decreto que reconheceu tal situação no país, após inúmeras reformas de suas decisões pelo E. TJSP e também pelo E. STJ, admite-se ser o caso de se curvar ao entendimento superior para se evitar recursos desnecessários. Com efeito, os tribunais fixaram o entendimento quase pacífico no sentido de que há necessidade de demonstração de nexo causal entre a conduta do réu e a calamidade pública decorrente da pandemia, devendo haver demonstração concreta de que o acusado se valeu de tal situação para cometer o crime. Tal não ocorre nos presentes autos, de modo que não é o caso de se reconhecer a incidência da agravante em questão. Forçosa, destarte, a condenação do réu nos termos acima expostos. Passo à DOSIMETRIA DA PENA.

Observando-se os elementos norteadores contidos nos artigos 59 e 60 do Código Penal e ainda o artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, dada a natureza nociva dos entorpecentes encontrados em poder do réu, os quais, ainda, estavam em diferentes formas (em pó e na forma de "crack") a revelar elevado e devastador efeito psicotrópico, tratando-se de drogas com alto poder viciante, autoriza-se a fixação da pena acima do mínimo legal, vez que tais circunstâncias excedem o desvalor inerente ao tipo. Anoto que a jurisprudência vem na linha do entendimento do juízo, confira-se: "A natureza nociva da substância entorpecente apreendida - cocaína - constitui fundamentação idônea a ensejar maior apenação na primeira etapa da dosimetria, pela desfavorabilidade das consequências do delito." (HC 141092/MS). Assim, majoro a pena-base do réu em 1/6, ficando em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

O réu é reincidente pela 2ª Vara Criminal de Osasco (autos nº 0006982-41.2018.8.26.0635 - trânsito em julgado para a defesa em 03/11/2020 - fls. 142 e confessou integralmente a prática delitiva. Esta magistrada adota o entendimento de que no concurso da agravante da reincidência e da atenuante da confissão deve prevalecer aquela, nos termos do artigo 67 do Código Penal. No entanto, o STJ, quando do julgamento do tema 585 em recurso repetitivo (RESP nº 1.341.370-MT) assentou o entendimento de que deve haver compensação de tais circunstâncias, motivo pelo qual, nesta segunda fase da dosimetria, a pena remanescerá inalterada. Deixo de aplicar a causa de diminuição de pena do artigo 33, §4º da Lei Antidrogas, tendo em vista que se trata de réu reincidente.

Com efeito, o legislador não estabeleceu que apenas a reincidência específica é capaz de afastar a incidência de causa de diminuição de pena, sendo certo que conceito de reincidência é objetivo e legalmente previsto.

Quanto ao regime de pena, declarada a inconstitucionalidade incidental do preceito legal que determina a adoção de regime inicial fechado (STF, HC 111.840/ES), passa-se à análise da questão. Com efeito, entende-se que seja aplicável regime mais severo do que aquele que o seria com base no simples valor aritmético da pena ora aplicada. Isto porque, trata-se de réu reincidente e, ainda, a gravidade em concreto do delito em questão, justifica o regime fechado, tendo em conta a relevante diversidade dos entorpecentes apreendidos, representando maior risco para a sociedade, pois causador de maior dependência química, sendo assim mais nocivo para a saúde pública, bem jurídico tutelado pelo legislador. Frise-se, por fim, que o delito ora em questão é daqueles que mais desassossego traz para a sociedade paulistana, tendo em vista ser crime potencializador de outros delitos, já que boa parte dos agentes comete crimes sob efeito de drogas ou para quitação de dívidas oriundas da aquisição de entorpecentes. Neste sentido: STJ, RHC 37.637/SP, 5ª Turma, rel. Min. Moura Ribeiro.

Deixo de aplicar o artigo 387, § 2º do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 12.736/2012, por entender que tal dispositivo é impossível de ser aplicado no Juízo de primeiro grau. A progressão de regime é matéria atinente ao Juízo das execuções criminais, devendo ser aferido não apenas o tempo de cumprimento da pena, como também se o sentenciado possui mérito para a progressão. Além disso, considero tal dispositivo inconstitucional, uma vez que viola os princípios da isonomia e da individualização da pena. Ao se considerar somente o

tempo de prisão provisória para a fixação do regime inicial, aquele que ficou solto durante o processo é tratado de forma prejudicial com relação àquele que ficou preso, uma vez que este poderá ter direito ao regime inicial mais benéfico tendo como base apenas o tempo de pena cumprido provisoriamente.

As condições econômicas do réu são modestas, assim fixo o valor de cada dia-multa no piso legal.

Ante todo o exposto e o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para o fim de CONDENAR, por infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, o réu MARCELO ALBURQUEQUE DE ALMEIDA, às penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial fechado.

As mesmas razões que recomendaram a custódia do acusado no curso do feito permanecem ainda presentes, vendo-se ainda reforçada a necessidade da cautela uma vez que, determinada a imposição de penas ao acusado, patente o risco de que solto venha procurar obstar a aplicação da lei penal, pondo-se em fuga. Ademais, trata-se de réu reincidente por grave crime de roubo, o qual se encontrava em cumprimento de pena em regime aberto quando da prática do delito apurado no presente feito (fls. 141), a indicar que sua liberdade seja um risco para a ordem pública. Deixo de lhe facultar, assim, o recurso em liberdade. Recomende-se o réu no estabelecimento em que se encontra recolhido.

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e expeça-se guia de recolhimento definitiva.

Custas na forma da lei.

Oficie-se para destruição do entorpecente apreendido independentemente de trânsito em julgado.

Tendo em vista que o dinheiro encontrado com o réu não teve sua origem lícita demonstrada nos autos, estando nitidamente atrelado ao tráfico de entorpecentes, em razão da sentença condenatória ora proferida, determino seu perdimento nos termos da lei. Oportunamente, oficie-se para transferência do valor e, nos termos do COMUNICADO CG Nº. 805/2019 da E. Corregedoria Geral da Justiça, oficie-se para comunicação sobre o perdimento, encaminhando-se o ofício para a Esplanada dos Ministérios, Bloco T – Ministério da Justiça e Segurança Pública, Edifício Sede, sala 208, Brasília, Distrito Federal, CEP: 070064-900.

Quanto ao laudo de fls. 152/155, anoto que não há providências a serem tomadas, ante a negativa por parte do réu de que tenha sofrido qualquer agressão pelos policiais.

Defiro o quanto requerido pelo Ministério Público, determinando a extração de cópias das principais peças dos autos, em especial do termo de audiência, com encaminhamento de link de acesso às gravações, para instauração de inquérito policial para apuração de eventual crime de falso testemunho com relação a Carlos Eduardo.

P.R.I.

São Paulo, 25 de abril de 2022.

CARLA DE OLIVEIRA PINTO FERRARI
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA